

1501972-45.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... com ele, foi preso na rua Dom Infante por tráfico. Afirmou que os policiais já tinham ido na sua casa realizar diligência, pois Caio realizava tráfico de drogas na rua Dom Manuel. Por fim, afirmou que o menor Alex também já foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501972-45.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2348593/2021 - 02º D.P. PIRACICABA, 22099029 - 02º D.P. PIRACICABA, 5136/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2348593 - 02º D.P. PIRACICABA, 2348593/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO HENRIQUE CRUZ PROSPERO

Réu Preso

Contr. nº 2022/000017

Aos 08 de março de 2022, às 16:00 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu JOÃO HENRIQUE CRUZ PROSPERO (PRESO CDP Piracicaba). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PMS VANESSA GABRIELE ROUTH e ALBERTO DA COSTA FILHO

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os

trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PMS Adalberto e PM Vanessa) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a) 1. O(s) réu(s) JOÃO HENRIQUE CRUZ PROSPERO, qualificado nos autos, foi(ram) denunciado(s) e está(ão) sendo processado(s) como incurso(s) no artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. De acordo com a denúncia, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 14 horas e 10 minutos, na rua Pedro Grosse nº 6, bairro Vila Cristina, nesta cidade e comarca, JOÃO e o adolescente José Alex Lima da Silva, em concurso, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 54 porções de maconha (vegetal contendo THC), com massa líquida de 131,1g; 1 porção de maconha (vegetal contendo THC), com massa líquida de 872,3g; 3 invólucros de plástico contendo cocaína, na forma de pedras de "crack", com massa líquida de 73,3g; 111 eppendorfs contendo cocaína, em pó, com massa líquida de 21,1g; 1 porção de cocaína, com massa líquida de 299g; e 3 invólucros de plástico contendo cocaína, na forma de pedras de "crack", com massa líquida de 141,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. O processo teve trâmite regular, conforme se verifica a fls. 115, 121/127, 134/135 e 136/137. 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4 e ss.), auto de exibição e apreensão, laudo de constatação de fls. 15/21, fotografia de fls. 22, laudo do exame químico-toxicológico de fls. 165/168 (com os esclarecimentos de fls. 170) e depoimentos colhidos. 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida, consistente nos depoimentos dos PMS Adalberto da Costa Filho e Vanessa Gabriele Routh. Os PMS contaram que, averiguando um "disque denúncia", foram ao local dos fatos. O réu e o adolescente saíam do imóvel, em aparente estado de abandono. Não havia porta na casa. Havia um sofá em pé que, talvez, fosse usado como porta. A dupla foi abordada. Entraram na casa e encontraram o entorpecente e os petrechos relacionados ao tráfico, com o auxílio do cão de faro. Não havia cama, nem aparência de que alguém habitava o local. O acusado admitiu que a mochila lhe pertencia, mas falou que a droga que ela continha não lhe pertencia. Na fase policial, o acusado admitiu que a mochila lhe pertencia (fls. 7). Em Juízo, negou o fato. A mochila, de fato, lhe pertencia. Não havia droga nela e sim roupa. Pretendia se mudar do local. O adolescente entrou na casa para tomar água. Seu colega (Caio Henrique) morava no local e havia sido preso por tráfico. Nesse cenário, a condenação é de rigor. 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que o réu não possui antecedentes desabonadores (fls. 97/99), ainda que se dedique ao tráfico desde a menoridade (1532633-97.2020.8.26.0451; exec. 0009991-10.2020.8.26.0451). Tal circunstância, repele o privilégio. 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). JOÃO HENRIQUE CRUZ PROSPERO foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Recebida a denúncia, o feito teve seu regular trâmite, sendo encerrada a instrução na presente audiência. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a ação penal deve ser julgada improcedente. De fato, inicialmente é o caso de se reconhecer que toda a prova produzida contra o acusado se originou de ação ilícita dos policiais militares, que, em tese, apreenderam substância entorpecente na moradia do acusado, porém violando a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal). Com efeito, tanto na fase policial quanto em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante declararam que estiveram no local dos fatos para apurar uma denúncia dando conta de que ali ocorria a prática de tráfico de drogas. Ali, depararam-se com o acusado e com um adolescente

inimputável, que saíam do imóvel. Eles foram abordados, porém nada de ilícito foi localizado. Na sequência, ingressaram na residência e mediante concurso com cão de faro, lograram localizar uma mochila contendo as substâncias descritas na inicial acusatória. Indagados sobre eventual autorização do réu para a entrada no local, os policiais divergiram: o policial Adalberto disse que sequer pediram permissão, enquanto Vanessa afirmou que houve o consentimento do acusado. De todo modo, que em seu interrogatório judicial, o acusado desmentiu essa informação, afirmando que os policiais não lhe pediram autorização, pois logo entraram. Assim, considerando a atual jurisprudência do C. STJ, o réu deve ser absolvido, pois para além de seus depoimentos dissonantes – saliente-se –, não há nenhuma prova que indique que o acusado realmente consentiu de forma livre e espontânea para o ingresso dos policiais em sua moradia. De fato, o C. STJ pacificou o entendimento de que é ônus do Estado comprovar a legalidade da ação com a apresentação de provas fidedignas no sentido de que a pessoa acusada consentiu voluntariamente com o ingresso dos agentes policiais em sua residência (HC 598.051/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021) A propósito, no julgamento paradigmático, foram fixados, entre outros, os seguintes pontos: a-) “Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva”; b-) “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”; -c) São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça”; d-) A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ou seja, não basta a mera alegação de que o acusado consentiu para entrada no local. É preciso que isso venha comprovado a partir de prova fidedigna, como por exemplo gravação audiovisual, termo assinado ou por meio de testemunhas isentas. Mas nada disso há. A diligência tampouco pode ser justificada pela existência de denúncia anônima, pouco importando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a aplicação das leis federais no âmbito do território brasileiro. Da mesma forma, é irrelevante a precariedade do imóvel, sob pena de se entender que os agentes estatais podem arbitrariamente entrar na casa de pessoas mais pobres. Portanto, nesse cenário, não existindo comprovação de que o réu permitiu que os policiais entrassem em sua casa, de rigor a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. No entanto, caso não acolhida a primeira tese defensiva apresentada, o réu

deve ser absolvido pela mais absoluta falta de provas quanto a autoria delitiva. Afinal, apurou-se que o nome do acusado em nenhum momento foi mencionado no disque-denúncia. Na verdade, o relatório aponta o adolescente Alex e um indivíduo de nome Robson como os principais responsáveis pelo tráfico no local dos fatos. Some-se a isso a informação de que o imóvel era precário, sem portão, do que se pode concluir que qualquer pessoa poderia ali entrar. A respeito disso, importante salientar ainda que o acusado declarou que morava com indivíduo que foi preso por tráfico - Caio Henrique Gonçalves (vide processo nº 1501951-69.2021.8.26.0599). Dessa forma, não há como se afirmar, com a certeza que exige o direito penal, que a droga pertencesse ao réu, já que qualquer um poderia ali ingressar. De outro lado, o acusado não foi surpreendido em ato típico de traficância. Tampouco tinha dinheiro ou droga consigo, quando abordado na via pública. Ou seja, as provas são absolutamente frágeis, pois remanesce séria dúvida sobre a propriedade da droga. E nesse cenário, o decreto absolutório se impõe, consoante art. 386, VII, do CPP. Todavia, caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, em caso de condenação pelo crime mais grave narrado na denúncia, requer-se a fixação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com suas implicações (regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos). Ou, então, que ao menos seja estabelecido o regime intermediário, já que se trata de acusado absolutamente primário. Por fim, requer-se seja conferido o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o princípio da presunção de inocência.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos.

JOÃO HENRIQUE CRUZ PROSPERO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 14 horas e 10 minutos, na rua Pedro Grosse nº 6, bairro Vila Cristina, nesta cidade e comarca, e o adolescente J. A. L. da S., em concurso, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 54 porções de maconha (vegetal contendo THC), com massa líquida de 131,1g; 1 porção de maconha (vegetal contendo THC), com massa líquida de 872,3g; 3 invólucros de plástico contendo cocaína, na forma de pedras de "crack", com massa líquida de 73,3g; 111 eppendorfs contendo cocaína, em pó, com massa líquida de 21,1g; 1 porção de cocaína, com massa líquida de 299g; e 3 invólucros de plástico contendo cocaína, na forma de pedras de "crack", com massa líquida de 141,5g (conforme laudo de constatação de fls. 15/21 e fotografia de fls. 22), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. BO de fls. 4 e ss.).

Narra a denúncia que a Polícia Militar recebeu o disque-denúncia nº W2111254539 dando conta do tráfico de drogas praticado no local dos fatos. Diligenciando, os PMs avistaram o acusado João Henrique e o adolescente José Alex saindo do mencionado imóvel, que se encontrava em aparente estado de abandono.

Narra, ademais, que a dupla foi abordada e entrevistada, seguindo-se a busca no interior do imóvel com o auxílio de um cão adestrado, providência que resultou no encontro da mochila pertencente ao réu, em cujo interior havia as substâncias entorpecentes acima discriminadas, bem como 2.000 eppendorfs vazios e 200 unidades de sacos plásticos, desses normalmente utilizados para embalo de porções.

Apreenderam-se, assim, as drogas e petrechos que o acusado e o adolescente tinham em depósito e guardavam para fins de tráfico.

Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida evidenciaram a destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 115). Defesa preliminar apresentada às fls. 121/127. Após, a denúncia foi recebida (fls. 134) e o réu foi citado (fls. 161).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes e o reconhecimento da causa de aumento de envolvimento de menor na prática do crime,

alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa arguiu ilicitude na ação dos policiais e, no mérito, pleiteou a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, afasto a tese defensiva de nulidade da prova em decorrência da realização da diligência policial sem mandado judicial.

A Constituição Federal expressamente autoriza a busca domiciliar sem prévia autorização judicial em casos excepcionais, como aqueles em que há flagrante delito.

Neste sentido dispõe o artigo 5º, inciso XI:

"A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" - gn.

O crime de tráfico, na modalidade "ter em depósito" substância entorpecente, é permanente.

E, no caso concreto dos autos havia fundadas suspeitas da prática do crime no local a autorizar a ação da polícia.

De fato, revelou a prova oral adiante a ser analisada, que a diligência policial foi precedida de informações por meio de disque-denúncia de que no endereço em questão indivíduos recebiam drogas, as quais eram fracionadas e comercializadas na residência e em um bar vizinho, razão pela qual os milicianos se dirigiram ao local e surpreenderam o réu e o adolescente, cujas características coincidiam com as de um dos traficantes indicado na denúncia (de cor parda e usava óculos), saindo juntos do imóvel, razão pela qual os abordaram. O ingresso na casa, que aparentava estar em estado de abandono, se deu na sequência, pois, com as informações anônimas e com o encontro de um dos suspeitos saindo dali, havia sérios indícios da prática de tráfico no local. Assim, com ajuda de um cão farejador, foi localizada uma mochila, no interior da qual se encontravam as drogas e petrechos relacionados ao tráfico.

Tais elementos corroboraram a fundada suspeita da ocorrência do crime permanente no imóvel a justificar a busca e apreensão sem mandado judicial.

Neste sentido jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns recentes julgados:

"Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de cocaína na forma de crack - Insurgência do réu - Preliminar: Ilicitude da prova obtida - Inocorrência - Fundada suspeita apta a autorizar a entrada dos castrenses no imóvel - Crime permanente. E mesmo que assim não fosse, vale dizer que se trata de imóvel não habitado, o que afasta a pretendida nulidade na busca e apreensão realizada pelos agentes públicos, de acordo com o recente julgamento do Col. STJ (HC 588445/SC) - Rejeição. Mérito: Autoria e materialidade comprovados - Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório - Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Pleito de desclassificação para o art. 28 da norma em comento - Inadmissibilidade - Mercancia evidenciada - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em razão da potencialidade lesiva do crack - Respeitado o entendimento do nobre julgador, ainda que o entorpecente apreendido tenha alto poder viciante, verifica-se que a quantidade (12,17 gramas) não se mostra expressiva a ponto de justificar a pretendida exasperação - Segunda fase - Presença das agravantes de calamidade pública (art. 61, II, "j", CP) e de reincidência específica, na fração de 1/3 - Em que pese o entendimento do d. sentenciante, não há relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do tráfico de drogas - Afastamento - Incidência da agravante de reincidência específica, na fração de 1/5, patamar esse adotado por esta câmara (06 anos de reclusão e 600 dias-multa) - Terceira fase - Redutor que não incidiu no caso - Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da benesse contida no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, pois ausente os requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na

segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja "bis in idem" - Regime fechado - Recurso provido em parte para redimensionar o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença." (TJSP - Apelação Criminal 1500424-03.2021.8.26.0302; 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 27/09/2021) - g.n.

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Preliminar de nulidade. Afastada. Ausência de mandado de busca e apreensão. Desnecessidade. Neste caso, havia fundada suspeita do envolvimento da ré que foi positivado, além do encontro de drogas e caderno de anotações relacionados as drogas. Tratando-se de crime permanente não se configura nulidade no flagrante ou violação ao domicílio por falta de mandado. Além disso, também há afirmativa de que se tratasse de apartamento abandonado: local aberto, acessível a qualquer pessoa. Ingresso de policiais ali não afeta Direito Constitucional de inviolabilidade, por não ser lar, residência, domicílio, mas sim local para prática de crimes. - Confissão extrajudicial da ré quanto ao envolvimento com o tráfico, corroborada pelos depoimentos dos policiais. Redução da pena - artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Não aplicada. Ausência de requisito. Regime fechado. Mantido. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP - Apelação Criminal 1500783-76.2020.8.26.0628. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - j. 24/11/2021) - g.n.

"Ação Penal - Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico - Sentença condenatória - Apreensão de aproximadamente 1 tonelada de substâncias tóxicas (cocaína e maconha) - Insurgência dos réus - Preliminares: A) ilicitude da prova obtida - Inocorrência - Crime permanente - Imóvel não habitado - Utilização do local para armazenamento de drogas - Casa que não possui qualquer vestígio de habitação, o que afasta a pretendida nulidade na busca e apreensão realizada pelos agentes públicos, de acordo com recente julgado do Col. STJ (HC 588445/SC) - Rejeição. B) nulidade da investigação realizada pela polícia militar - Inocorrência - Dicção do disposto no art. 144, parágrafo 4º, da Constituição Federal - Função investigativa que pode ser realizada por outros órgãos estatais - Rejeição. C) cerceamento de defesa - Alegação de que o sistema virtual apresentou falhas e impediu a compreensão dos depoimentos - Inexistência - Juízo que em observância aos princípios constitucionais e processuais penais, tomou todas as providências necessárias a fim de evitar prejuízos às partes - Rejeição. Mérito - Autoria e materialidade comprovados - Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório - Reunião estável, permanente e com definida divisão de tarefas para a prática delitiva - Dicção do disposto nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria fixada corretamente pelo juízo - Regime fechado mantido - Dicção do disposto no art. 33, parágrafo 2º, alínea 'a', do Código Penal - Perdimento do veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes (Fiat-Strada, placas FNH-1665) - Incidência do art. 63, I, LA - Automóvel (Fiat-Strada, placas AYK-6607) que não se pode afirmar que tenha sido utilizado para o tráfico ou que seja proveniente do comércio ilícito - Restituição devida - Recurso do réu Everton não provido e recurso do réu Hugo provido em parte, para a restituição do bem supramencionado. Mantida, no mais, a r. sentença. ugo provido em parte." (TJSP - Apelação Criminal 1501056-88.2020.8.26.0229. 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 24/06/2021) - g.n.

"APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Preliminar de ilicitude da prova - Violação de domicílio - Estado permanente de flagrância que justifica o ingresso dos policiais no local - Preliminar afastada - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o réu tinha em depósito e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Penas redimensionadas para evitar acréscimo cumulativo na primeira fase da dosimetria - Não aplicação do benefício contido no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da dedicação do réu a atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa -- Regime prisional inicial fechado compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000586-

08.2018.8.26.0616; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022).

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 09/12;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e fotografia de fls. 22;
- 3) laudo de constatação preliminar de fls. 15/21 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 165/168, complementado pelo ofício de fls. 170, os quais atestaram resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas;
- 4) cópia do BO/PM de fls. 173/181; e
- 5) cópia do disque-denúncia nº W2111254539 de fls. 182/184.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05), o réu negou a prática delitiva. Disse que se encontrava no local dos fatos, onde reside, quando os policiais adentraram o imóvel com cão farejador e depois saíram de lá com a droga. Informou que a mochila apreendida lhe pertencia, mas alegou que desconhecia as drogas nela encontradas. Interrogado em juízo (gravação), novamente negou a infração, dizendo que morava na casa, mas estava "de mudança". No dia dos fatos, quando saiu na rua, encontrou com o adolescente Alex e mais dois indivíduos. Eles lhe pediram água. Nesse momento, os policiais os abordaram e entraram na casa sem pedir autorização. Afirmou que a casa não tinha porta, nem janela, mas tinha cama. Admitiu a propriedade da mochila que os policiais apreenderam, mas disse que nela só havia roupas e não drogas. Disse não saber a quem pertenciam as drogas apreendidas e que os policiais disseram estar em sua mochila e que lhe apresentaram do lado de fora da casa. Afirmou que cinco dias antes seu colega Caio Henrique Gonçalves, que morava com ele, foi preso na rua Dom Infante por tráfico. Afirmou que os policiais já tinham ido na sua casa realizar diligência, pois Caio realizava tráfico de drogas na rua Dom Manuel. Por fim, afirmou que o menor Alex também já foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Adalberto da Costa Filho declarou que, no dia dos fatos, receberam o disque-denúncia W2111254539, o qual indicava que no endereço da denúncia havia uma casa abandonada que era utilizada por indivíduos que recebiam drogas, as quais eram fracionadas e comercializadas ali e em um bar vizinho, bem como que um dos indivíduos, conhecido como Alex, era de cor parda e usava óculos. Diante dessas informações, deslocaram-se até o endereço indicado, onde avistaram dois indivíduos saindo da casa, um deles com as características repassadas no disque-denúncia. Abordaram-nos e deram-lhes ciência da denúncia anônima. Ambos se identificaram, o adolescente como sendo José Alex, e o maior como sendo o réu, o qual disse que morava no imóvel. No entanto, o local não era uma casa habitável, mas sim um imóvel abandonado (não tinha porta nem cama, mas apenas roupas jogadas no chão e um sofá levantado que, provavelmente, servia de porta). Submeteram-nos à busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com o acusado e com o adolescente. Questionados se havia algo de ilícito no imóvel, ambos negaram. Entretanto, diante das informações, realizaram uma busca no local com ajuda do cão de faro, sendo localizada uma mochila embaixo de um armário de alvenaria. No interior dessa mochila havia 01 tijolo e 54 pacotes de maconha, 03 pedras brutas de crack, 04 porções e 111 microtubos de cocaína, além de aproximadamente 2.000 microtubos (ependorfs) vazios e 02 embalagens (200 unidades) de sacos plásticos. Ao serem indagados, o réu admitiu a propriedade da mochila e, quando lhe deram ciência da existência das drogas ali, ele não soube explicar, alegando desconhecer sua existência. O adolescente negou relação com as drogas. O réu e o adolescente acompanharam a busca da porta.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação) pela policial militar Vanessa Gabriele Routh, a

qual acrescentou que o réu alegou que seu colega de moradia havia sido preso há pouco tempo naquele local.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal.



Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSO JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra de agente público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse contexto, não há dúvidas da prática do tráfico pelo réu e pelo menor Alex, que o acompanhava no dia dos fatos.

Com efeito, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que, de posse do disque-denúncia apontando o imóvel como local de fracionamento e comércio de drogas, dirigiram-se até o local e surpreenderam o réu e o adolescente saindo da residência e os abordaram. Após negarem a existência de entorpecentes no imóvel, com a ajuda de cão farejador, encontraram a mochila pertencente ao acusado (ele admitiu a propriedade da mochila não só na fase informativa, mas também em juízo), no interior da qual foram encontradas todas as drogas e petrechos para o tráfico.

Registro que a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes que o réu e o menor tinham em depósito confirmam o destino mercantil, pois incompatíveis com a situação de mero usuário.

Some-se a isso o fato de parte dos entorpecentes já estarem embalados individualmente, da forma como comumente são comercializados, bem assim pelo fato de junto deles terem sido apreendidos petrechos relacionados ao tráfico (aproximadamente 2.000 eppendorfs vazios e 200 unidades de sacos plásticos), demonstrando que ali mesmo ocorria o fracionamento e acondicionamento das substâncias para sua posterior distribuição e comercialização.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esbanja a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser

visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso, inciso VI, da Lei 11.343/06. Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 97/98).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. A fim de se evitar "bis in idem", a expressiva quantidade e diversidade de drogas mantida em depósito pelo acusado não será considerada para o fim de se majorar as suas penas na primeira fase, porquanto servirá de fundamento para afastar o privilégio.

Assim, aplico-lhe as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a atenuante da menoridade, mas deixo de diminuir as penas, pois circunstâncias atenuantes não autorizam a redução aquém do mínimo legal.

Não há agravantes.

Reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, em razão de a infração ter sido cometida em concurso com adolescente, imperioso o aumento das penas em 1/6, o que perfaz cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que, embora primário, o réu possui passagem na Vara da Infância e Juventude com condenação pela prática de ato infracional equivalente a tráfico de drogas (fls. 108/109), tendo recebido aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida, o que demonstra que, já há algum tempo, vem se dedicando a essa atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Não bastasse, era expressiva a quantidade de drogas e havia diversidade, o que, aliado à existência de petrechos destinados ao seu embalo, demonstram tratar-se de crime de maior expressão, confirmando a convicção de que o réu não se tratava de traficante eventual, mas sim de traficante de maior envergadura, que tem feito dessa atividade ilícita seu meio de vida.

Registro que a aplicação da minorante exige a existência cumulativa dos quatro requisitos presentes no dispositivo supramencionado, quais sejam: a) agente ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

No caso dos autos não se fez presente o requisito indicado no item "c".

No sentido de que, em casos como esse, é incabível o privilégio, já se manifestaram as duas turmas do C. STJ:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE

DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVAÇÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Assentado pela instância antecedente que o paciente se dedica a atividade delitiva, uma vez que possui medidas socioeducativas em fase de execução, inclusive pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para se afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. 6. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". (Precedentes). 8. Hipótese em que o Tribunal de origem majorou a pena na fração de 1/5, tão somente pelo fato de terem sido reconhecidas 2 majorantes (art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006), impondo-se, portanto, o redimensionamento para a percentual mínimo (1/6). 9. Fixada a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 10. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração das majorantes para 1/6, ficando a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como para fixar o regime inicial semiaberto." (HC 529.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 12/11/2019). g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). NÃO APLICAÇÃO. PASSAGENS ENQUANTO MENOR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. PENA TOTAL SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE ABSTRATA E HEDIONDEZ DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENHIDA NÃO ELEVADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE

DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicá-la ao caso concreto em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pelo fato do paciente ostentar passagens anteriores enquanto menor de idade, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica à atividade criminosa, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. 3. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, de acordo com o disposto no enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os enunciados ns. 718 e 719 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal - STF. 4. Sedimentou-se, ainda, o entendimento segundo o qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º, do Código Penal em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. In casu, resta evidenciado o constrangimento ilegal na imposição do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, a fixação foi em razão da hediondez e da gravidade abstrata do delito, o que vai de encontro com a jurisprudência desta Corte Superior, mormente se considerarmos que a quantidade de droga apreendida não foi elevada (uma porção de maconha com peso de 39,16g). Dessa forma, considerando, ainda, que o paciente é primário, bem como o quantum de pena aplicado (5 anos de reclusão), correta a fixação do regime semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 5. Mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias superior a 4 anos, o pleito quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra-se prejudicado, haja vista que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento inicial da pena do paciente". (HC 512.197/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 06/08/2019).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Diz o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o paciente seja primário, portador de